

1502007-63.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: THOMAZ CORREA FARQUI

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... em sua moradia - Recurso não provido. Tráfico de drogas - Recurso defensivo: Prova ilícita mediante extorsão - Inocorrência - Agressões e constrangimento por parte dos agentes da lei não comprovada - Recurso não provido. Tráfico de drogas e resistência - Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória - inadmissibilidade - materialidade e autoria suficientemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502007-63.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502007-63.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152347/2022 - DEL.POL.GUARUJA, CF5139-1/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 2152347 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THOMAZ CORREA FARQUI

FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DOS SANTOS e MATHEUS GABRIEL TAVARES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma dos artigos 29, caput, e 69, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 04 de junho de 2022, por volta das 20 horas e 40 minutos, na Rua Um, nº 1, Viela C, Travessa C, Maré Mansa, nesta cidade e Comarca de Guarujá, os acusados, qualificados a fls. 22/23, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidades de desígnios, tinham em depósito e guardavam, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em setenta e duas porções, em dois

tijolos e em um saco com pequenas porções de maconha, pesando cerca de um quilo e setecentos gramas, e em cento e oitenta e dois frascos de cloreto de metileno, comumente conhecido por “lança-perfume”, perfazendo doze litros e quinhentos e vinte mililitros de tal substância, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 26/27, o auto de constatação preliminar de fls. 17 e as fotografias de fls. 30/31, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local acima citadas, os acusados, qualificados as fls. 22/23, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidades de desígnios, mantinham sob a guarda deles e ocultavam, munição de uso permitido, consubstanciada em dois cartuchos calibre 38, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 26/27 e as fotografias de fls. 25 e 28, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, os réus dedicavam-se ao narcotráfico no imóvel situado no endereço acima apontado, onde guardavam diversas porções de maconha e frascos de “lança-perfume”, tudo destinado ao espúrio comércio. É dos autos, ainda, que os denunciados, conquanto não contassem com autorização para tanto, obtiveram munições de calibre 38 e passaram a guardá-las e ocultá-las no imóvel referido.

Nas circunstâncias de tempo acima narradas, policiais militares realizavam operação pela Comunidade Maré Mansa, ocasião em que avistaram o indiciado Matheus na janela do aludido imóvel, de onde vinha forte odor de maconha. Ato contínuo, após notar a presença da guarnição, Matheus saiu da janela e se dirigiu para o interior do imóvel, razão pela qual os agentes públicos determinaram sua saída do local, porém não foram atendidos. Diante de tal cenário, os agentes públicos aproximaram-se da janela da construção e então avistaram maconha em cima de um balcão existente na cozinha do imóvel, no primeiro cômodo do local. Na sequência, os policiais entraram no imóvel e, em revista pelo local, localizaram os denunciados, cada qual em um quarto. Matheus estava deitado em uma cama em um dos cômodos, ao passo que Fernando foi encontrado em um outro quarto, onde estavam as drogas acima descritas, distribuídas em diversas sacolas. Foram encontrados, ainda, neste segundo cômodo, a quantia de cento e doze reais em dinheiro, duas balanças de precisão, diversos frascos transparentes vazios, duas munições calibre 38, um caderno com anotações, dois rádios comunicadores com uma bateria sobressalente e um carregador. Seguiram-se as prisões em flagrante dos indiciados, a apreensão das drogas, das munições, do dinheiro e dos demais objetos referidos, assim como a remessa do caso ao distrito policial (fls. 71/74).

As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas (fls. 52/54 e 96/99). Os acusados foram notificados sobre a denúncia (fls. 104/105) e apresentaram defesas preliminares (fls. 89/94 e 110/11), que foram rejeitadas, sendo, por consequência, recebida a denúncia (fls. 125/127). Foram juntados aos autos os exames químico toxicológicos (fls. 118/120 e 122/124). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e quatro de defesa, sendo os réus interrogados, ao final (200/201).

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, argumentando que a materialidade e a autoria são certas e seguras (fls. 202/214). A defesa dos réus, por sua vez, pugnou pela nulidade do processo, diante da ilicitude das provas colhidas em irregular diligência policial, bem como pela quebra da cadeia de custódia. No mérito, requereu a absolvição, dizendo que a prova colhida é frágil e contraditória. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, pugnou pela fixação do regime inicial diverso do fechado para cumprimento da pena e o direito de apelar em liberdade (fls. 233/259 e 273/300).

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, destaco não prosperar a arguida quebra da cadeia de custódia. Isso

porque, ainda que se reconheça a discrepância entre o número do lacre constante no auto de exibição e apreensão de fls. 26/27 com aquele constante no laudo de fls. 118/120, este menciona claramente a relação do material analisado com o Boletim de Ocorrência relativo ao caso, qual seja, CF 5139-1/2022.

Além disso, o lacre dos demais itens apreendidos se coaduna com aquele indicado no laudo de fls. 141/145, sendo o mesmo caso quanto à maconha encontrada, conforme laudo de fls. 122/124, o que, por si só, bastaria para viabilizar o pleito acusatório.

No mais, não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO originou o Tema 280 da Repercussão Geral, segundo o qual “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

É justamente a exceção em destaque que se aplica ao caso em tela, no qual os policiais conseguiram sentir o odor da droga advindo do interior da casa, não bastasse, ainda, terem visto, pela janela, a partir da parte externa, os entorpecentes (o que resta confirmado pelas gravações obtidas pelas câmeras dos policiais – fls. 217).

Ademais, não há que se falar em pescaria probatória, pois a diligência policial não se deu ao acaso, mas objetivamente direcionada ao encontro dos entorpecentes previamente visualizados pela janela da residência, cujo forte odor chamou a atenção dos agentes policiais.

Destarte, em que pesem os esforços diligenciados pela douta defesa, não vislumbro irregularidade na atuação policial capaz de ensejar as mencionadas nulidades. Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, com meu destaque, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Portanto, rejeitar pura e simplesmente a prova encontrada sem considerar as circunstâncias do caso em tela, acabaria por violar o princípio da razoabilidade, prestigiando a prévia expedição de mandado judicial em detrimento da atuação policial, diante de explícito descumprimento da lei.

Neste sentido:

Tráfico de drogas – Recurso ministerial: aumento da pena-base – Admissibilidade – Quantidade considerável de droga apreendida – Observância dos arts. 59 e 68 do CP e 42 da Lei 11.343/06 – Aplicação do princípio da proporcionalidade – Benesse do § 4º, do art. 33 da lei de drogas inaplicável – Evidente vinculação à atividade criminosa de mercancia de substâncias entorpecentes ou cooperação com ela – Recurso provido. Tráfico de drogas – Recurso defensivo: Prova ilícita – Invasão de domicílio – Nulidade – Inocorrência – Crime permanente – Hipótese em que o agente permanece em estado de flagrante enquanto não cessar a permanência – Situação, ademais, em que a conduta anterior do réu justificou a ação policial em sua moradia – Recurso não provido. Tráfico de drogas – Recurso defensivo: Prova ilícita mediante extorsão – Inocorrência – Agressões e constrangimento por parte dos agentes da lei não comprovada – Recurso não provido. Tráfico de drogas e resistência – Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras dos policiais corroboradas por demais elementos carreados aos autos – Condenação mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500842-85.2020.8.26.0621;

Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aparecida - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022 - grifos não originais)

HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de nulidade do processo em razão da ilicitude das provas, tendo em vista a violação de domicílio. Impossibilidade. Situação de flagrância que autoriza o ingresso dos policiais militares independentemente da expedição de mandado de busca e apreensão. Pedido de revogação da prisão preventiva. Significativa quantidade de drogas apreendidas. Paciente reincidente específico e que estava em gozo de livramento condicional. Necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2113788-26.2021.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Aprazível - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021).

HABEAS CORPUS - Imputação de crime de tráfico de droga - Alegação de violação de domicílio e ilegalidade na prisão - Não é exigível a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso no local, uma vez que a prisão em flagrante deu-se por crime permanente - Alegação de nulidade de provas - Impossibilidade - É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas (STF) - A existência de condições pessoais favoráveis não pode, por si só, ensejar a liberdade - A prisão preventiva não configura cumprimento antecipado de pena (STJ) - Paciente condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 565 dias-multa, no valor unitário mínimo, sem recurso em liberdade - Inviabilidade de análise do contexto fático-probatório em sede de habeas corpus - Liberdade incabível - ORDEM DENEGADA. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2098321-07.2021.8.26.0000; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 21/06/2021 - grifos não originais)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGENTE QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses." (STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 656.042 SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento: 25/05/2021)

No mérito, o pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 16), auto de constatação preliminar (fl. 17), auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), fotografias (fls. 30/31), boletim de ocorrência (fls. 32/35), laudos de exame químico toxicológico (fls. 118/120 e 122/124 -

positivos para "lança perfume e maconha"), laudos periciais (fls. 141/145 e 146/148), bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa quanto ao crime em questão igualmente é certa e recai, sem dúvida, sobre os réus. Vejamos.

Interrogado sob o crivo do contraditório, o réu Fernando Antônio Souza dos Santos negou a prática dos crimes dispostos na inicial. Alegou que, na data em questão, sua companheira pediu que cobrasse um valor relativo fruto do trabalho dela junto a uma terceira mulher. Assim, pegou o dinheiro e, ao retornar, passou por um campo de futebol que fica na "Maré Mansa", onde então avistou Matheus. Como fazia um tempo que não se viam, acabou por tomar uma cerveja com o corréu. Em seguida, este disse que iria devolver uma chave, de modo que o acompanhou. Ao chegarem no local, fumaram maconha e viram três meninos passarem, correndo. Ato contínuo, Matheus informou que havia policiais no lugar, razão pela qual decidiram entrar na moradia. No interior desta, ouviu barulho dos policiais ingressando no local. Como já tinha passagem pela polícia, ficou com medo e se evadiu por uma porta, enquanto Matheus saiu por outra. Apesar disso, ambos foram detidos. Os policiais disseram ter encontrado entorpecentes na residência, o que não pode confirmar, pois não os viu localizando as drogas, tampouco visualizou qualquer entorpecente no local. Por fim, questionado a respeito da discrepância de sua narrativa com a versão apresentada em sede policial, na qual afirmou que ambos foram fumar maconha na casa de Matheus, o réu sustentou que sua versão não é contraditória, e que eventual discordância se deu porque os policiais que lavraram o termo de interrogatório entenderam errado a versão que naquela ocasião a eles apresentou.

Também interrogado em Juízo, Matheus Gabriel Tavares dos Santos negou os delitos em questão, afirmando que os entorpecentes apreendidos pertenciam a um terceiro chamado Davi. Este havia pedido que ficasse com a chave da casa na Maré Mansa, onde havia algumas bisnagas de maconha, recebendo, em contrapartida, duzentos reais e uma porção da droga. Concordou e, por isso, ficou com a chave da residência. Na data dos fatos, enquanto jogava bola no campo, avistou o corréu Fernando. Então, chamou o corréu, com quem bebeu. Em seguida, convidou Fernando a acompanhá-lo até a mencionada casa, onde entregaria a chave para Davi. Chegando ao local, enquanto esperavam por Davi, três moleques passaram por eles, correndo, instante em que dispensaram no chão duas munições, as quais pegou para si. Após, notaram a aproximação de policiais, razão pela qual adentraram na moradia em questão. Entretanto, os policiais também entraram no local e os detiveram. Por fim, disse que nunca tinha entrado na casa em questão, pois sua função era apenas permanecer na posse da chave da residência enquanto o terceiro chamado Davi resolvia questões pessoais em São Paulo.

Embora o corréu Matheus tenha admitido saber que entorpecentes eram armazenados no interior da casa em questão, a versão exculpatória por ele apresentada é completamente inverossímil, não fazendo o menor sentido que um terceiro traficante lhe pagasse para guardar uma casa sem nunca adentrar nela, vez que o objetivo claramente era o de guardar as drogas em cujo interior estavam. Ademais, não é lógico que o terceiro chamado Davi (cuja existência sequer foi comprovada) tenha lhe confiado as chaves do imóvel em questão mediante contraprestação financeira. Afinal, se a casa estava abandonada e trancada, bastaria que o terceiro levasse consigo a chave do imóvel, sendo, portanto, prescindível a "contratação" dos serviços do réu.

De qualquer forma, as negativas dos réus estão isoladas nos autos, tendo sido infirmadas pelas demais provas colhidas, as quais bem comprovaram a versão acusatória.

Ouvidos sob o crivo do contraditório, Danilo Pena Carneiro e Jurandi Rufino de Souza Junior, policiais militares, harmonicamente disseram que, na ocasião,

diligenciavam pela comunidade Maré Mansa, quando, passando pelos corredores e becos, visualizaram o corréu Matheus na janela de uma casa. Este, ao perceber a presença dos policiais, entrou na residência. Como sentiram forte odor de maconha vindo do local, decidiram se aproximar e, ainda do lado de fora, olhando através da janela, viram entorpecentes em cima do balcão da cozinha. Então, ordenaram que o acusado saísse do imóvel, porém não foram atendidos. Desse modo, entraram na residência e abordaram os acusados, que correram para quartos distintos. No quarto em que Matheus estava, não havia nada de ilícito, porém, no cômodo para o qual Fernando se dirigiu, foram encontradas diversas porções de maconha e lança perfume, bem como embalagens, caderno com anotações do tráfico e rádios comunicadores, que, segundo o policial Jurandi, contavam com uma bateria sobressalente e um carregador, além de certa quantia em dinheiro e duas munições calibre 38. Questionado, Fernando disse que tinha ido ao local apenas para fumar maconha com Matheus, que, por sua vez, confirmou tal versão, afirmando ser ele o dono dos entorpecentes, os quais não eram vendidos na biqueira, mas para “playboys”, em festas. Por fim, o policial Jurandi acrescentou que ainda no local dos fatos Matheus, inquirido, afirmou que passou a utilizar o imóvel há cerca de duas semanas, quando percebeu que ele estava abandonado.

Anoto, neste ponto, que os relatos prestados pelas testemunhas de acusação são coerentes e harmônicos entre si, e, ademais, não foi apresentada razão plausível para se desacreditá-los, de forma a explicar a razão pela qual seus autores mentiriam em juízo com o fim de incriminar inocentes, ainda mais se, como no caso, os depoentes sequer conheciam os acusados antes dos fatos.

Não bastasse, acrescento que as testemunhas Danilo Pena Carneiro e Jurandi Rufino de Souza Junior, policiais militares, como servidores públicos que são, gozam de credibilidade presumida, sendo seus testemunhos plenamente válidos, sobretudo porque não há nos autos razões concretas que possam trazer-lhes suspeição: “Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266).

Este também é o firme entendimento do E. STJ: De acordo com o entendimento desta Corte, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

Friso, ainda, que a narrativa dos policiais resta confirmada pelas gravações de fls. 217, que bem confirmam que eles estavam em operação pelo local dos fatos quando, desconfiando da conduta dos réus, observaram pela janela da casa (que encontrava-se aberta), concluindo, então, pela traficância (o que justificou, inclusive, e como já dito, o ingresso forçado na residência).

Por sua vez, as testemunhas de defesa Valdemir Tavares de Sousa, Darley da Silva Barbosa Ferreira, Luana Maria da Silva e Elisângela Maria da Silva pouco contribuíram para a elucidação da verdade, pois não presenciaram a prisão dos acusados, tampouco a busca realizada na residência em questão. Assim, limitaram-se a dizer que os acusados eram trabalhadores, desconhecendo qualquer envolvimento destes com o tráfico de drogas.

Portanto, diante das provas produzidas e analisadas, ao contrário do sustentado pela defesa, a autoria dos réus é evidente em relação ao crime de tráfico de drogas.

As circunstâncias dos fatos confirmam, ademais, como se pôde notar, o destino mercantil das drogas. Isto porque, os réus foram surpreendidos com setenta e sete porções de maconha, pesando 1631,9g, e cento e oitenta e dois frascos de lança-perfume, perfazendo 12.520 ml, conforme laudos toxicológicos de fls. 118/120 e 122/124, volume claramente incompatível com eventual uso para consumo pessoal.

Não bastasse a substancial quantidade de entorpecentes, foi encontrado com os réus dois cartuchos íntegro de calibre .38 da marca CBC, dois rádios comunicadores, duas balanças de precisão e um caderno com anotações do tráfico, nos termos do laudo de fls. 141/145, bem como diversas embalagens plásticas para o acondicionamento de drogas, conforme laudo de fls. 146/148.

Acrescento que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

No mais, aponto que os réus são reincidentes, razão pela qual é incabível a aplicação da redução de pena disposta no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, não há como se acolher o pedido para condenação dos réus pelo porte das munições apreendidas.

Foram encontradas duas munições, desacompanhada de arma apta a dispará-las. Assim, bem se nota que a conduta não tem significância suficiente para implicar a intervenção penal, sobretudo se considerado que dela não é possível, sequer em tese, haver lesão a bens jurídicos tutelados.

Deste modo, entendo que a conduta em questão, consistente na posse de duas munições, sem qualquer arma no local, é materialmente atípica.

Assim:

PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES (USO RESTRITO). Recurso defensivo. Absolvição. Possibilidade. Conduta materialmente atípica. Inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado. PROVIMENTO. (TJSP; Apelação Criminal 0053519-07.2018.8.26.0050; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. Artigo 14, da Lei n.º 10.826/03. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Posse de três munições de uso permitido, calibre 38, desacompanhadas da respectiva arma de fogo. Princípio da insignificância. Aplicabilidade. Presença dos requisitos verificada. Ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Inteligência da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Absolvição decretada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500911-76.2018.8.26.0431; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pederneiras - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/07/2022; Data de Registro: 24/07/2022)

Apelação. Posse ilegal de munições de uso permitido (artigo 14, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03,). Sentença condenatória. Recurso defensivo almejando a absolvição por insuficiência probatória. Acolhimento. Crime de porte ilegal de arma de fogo. Absolvição admissível. Ausência de potencialidade lesiva da conduta. Aplicação do princípio da insignificância. Artigo 386, inciso III, do CPP. Sentença alterada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500494-76.2019.8.26.0306; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de José Bonifácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de

Registro: 28/01/2022)

De qualquer modo, ainda que se entendesse de forma diversa, a absolvição seria mesmo de rigor. Isso porque, o objeto jurídico do crime imputado aos réus, ou seja, o bem jurídico a que se pretende tutelar, é a segurança pública. Assim, ainda que se entenda estar-se diante de crime de perigo abstrato, cuja probabilidade de dano, com o mau uso da munição, é presumida de forma absoluta pelo legislador, é mister que a arma ou munição seja potencialmente lesiva. Do contrário, ou seja, inexistindo potencialidade de dano (como ocorre com a arma quebrada ou a munição sem pólvora), há crime impossível, já que o bem jurídico a que se pretende tutelar sequer em tese (abstratamente) poderá ser afetado.

Neste sentido diversos e recentes julgados do E. TJ/SP:

APELAÇÃO. Posse irregular de munição de uso permitido. Recurso defensivo. Nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Acusado que afirmou em Juízo ter autorizado o ingresso dos policiais militares em sua residência e indicado onde guardava as munições apreendidas. Preliminar rejeitada. Mérito. Laudo pericial que atestou a provável potencialidade lesiva das munições apreendidas, sem a submissão a testes de disparo. Ausência de comprovação da materialidade delitiva. Recurso provido para absolver o apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. (TJSP; Apelação 0070131-32.2012.8.26.0114; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data de Registro: 07/06/2017);

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO - Materialidade do delito não demonstrada - Laudo pericial que não atestou satisfatoriamente a potencialidade lesiva da munição apreendida - Absolvição em relação a esse delito decretada. (TJSP; Apelação 0002653-84.2015.8.26.0604; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sumaré - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro: 22/05/2017).

APELAÇÃO. Posse ilegal de munição de uso permitido. Absolvição. Recurso ministerial. Laudo pericial inconclusivo quanto à potencialidade lesiva das munições apreendidas. Ausência de comprovação da materialidade. Sentença absolutória mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0002292-36.2010.8.26.0477; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro: 14/06/2017)

PORTE DE MUNIÇÃO - calibre 38 - perícia que não constatou a potencialidade lesiva dos projéteis - ausência de prova da materialidade - absolvição da ré em relação a este delito - provimento do recurso da ré Crislaine para este fim. (TJSP; Apelação 0000641-42.2011.8.26.0312; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Juquiá - Vara Única; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 27/10/2016).

No caso dos autos, o laudo pericial de fls. 141/145 limitou-se a informar a existência de dois cartuchos não deflagrado (o que, aliás, prescindia de perícia, pois para tanto não se mostram necessários conhecimento técnicos específicos). Não houve teste de disparo ou outros testes que demonstrassem, concretamente, a potencialidade lesiva da munição apreendida, de modo que se impõe, também por este motivo, a absolvição.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido ministerial e CONDENO FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DOS SANTOS e MATHEUS GABRIEL TAVARES DOS SANTOS, já qualificados, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e ABSOLVO-OS da prática do crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

Passo a fixar a pena de acordo com o critério trifásico, o que faço conjuntamente, pois similar, para ambos os réus, juízo de reprovação.

Analizadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a fim de evitar inconstitucional bis in idem, os antecedentes dos réus serão analisados na próxima fase. No mais, os réus agiram com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar suas condutas sociais, sendo que pouco se colheu a respeito de suas personalidades. O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil.

Entretanto, observo que a reprimenda merece ser exasperada, tendo em vista o volume de drogas apreendidas, consistente em aproximadamente um quilo e setecentos gramas de maconha e mais de doze litros de cloreto de metileno, quantidade capaz de alcançar um número considerável de usuários, portanto com efeitos especialmente deletérios. Sendo assim, diante da grande quantidade da droga apreendida, e com fundamento no art. 42 da lei de regência, fixo a pena base do acusado em 1/8 acima do mínimo estabelecendo-a, nesta fase, o patamar de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, pois, como dito, os réus praticaram o crime após condenados, em definitivo, por delitos anteriores (fls. 37 e 39 – autos nº 1501001-60.2018 da 3ª Vara Criminal do Guarujá). Desse modo, aumento suas penas em 1/6, estabelecendo-as em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 650 dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, ficam os réus condenados, em definitivo, à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 650 dias-multa.

Ausente prova da capacidade econômico-financeira dos réus, ficará o valor do dia-multa no mínimo legal.

A pena é superior a 4 anos e os réus são reincidentes, razão pela qual não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Embora a pena não ultrapasse 8 anos, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a reincidência, fixo o regime inicial fechado nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal. Eventual detração não altera o regime inicial fixado, pois não alcançado o interregno mínimo legal para a progressão.

Permanecendo inalteradas as razões que ensejaram a manutenção da custódia cautelar dos acusados, e tratando os autos de crime equiparado a hediondo e que traz evidentes repercussões negativas à sociedade local, deverá o acusado permanecer custodiado. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.

Sem custas, por se tratar de réus pobres na acepção jurídica do termo.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Publique-se. Intime-se.

Guaruja, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA